

1501426-13.2021.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ALBIERI

Comarca: Nova Granada

Foro: Foro de Nova Granada

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... que é conhecido pela alcunha 'Boliviano', e pela prática de tráfico de drogas, com prisão anterior pela prática do mesmo delito. Droga apreendida com o réu que renderia entre trinta a quarenta porções de crack - Tráfico de drogas consumado - Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas - Prova que demonstrou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nova Granada

Foro de Nova Granada

Vara Única

Av. Dr. Hildeberto de Albuquerque Ferreira, 1001, Nova Granada-SP - cep 15440-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501426-13.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501426-13.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2265463/2021 - DEL.POL.NOVA GRANADA, 20539482 -

DEL.POL.NOVA GRANADA, 2265463 - DEL.POL.NOVA GRANADA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

Edmar Sergio Tamura Macera e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALBIERI

Vistos.

EDMAR SÉRGIO TAMURA MACERA foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, 'caput', c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 28 de setembro de 2021, por volta das 09h59min, na Rodovia SP-322, altura do Km 500, no município de Icém, nesta comarca de Nova Granada, previamente ajustado com Lucimar Alves da Silva e Dayani Cristina de Aguiar, transportaram, para fins de tráfico, 180 (cento e oitenta) tijolos de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha", pesando 111,4 Kg (cento e onze quilogramas e quatro decigramas), conforme o auto de exibição e apreensão (fls.12/13 - processo nº 1501426-13.2021.8.26.0559) e laudo de constatação (fls.18/21 - processo nº 1501426-13.2021.8.26.0559), drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme as circunstâncias narradas na denúncia.

Oferecida e recebida a denúncia (fls. 269/274 e 275/279), oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do réu.

Na decisão de fls. 364 foi determinada a suspensão da ação penal, bem como do decurso do prazo prescricional em relação ao réu.

O réu foi citado por edital (fls. 373/374 e 396).

Pedido de habilitação de defensor constituído às fls. 462 com apresentação de resposta a acusação às fls. 465/468.

Pedido de informações em Habeas Corpus com indeferimento da medida liminar em favor do réu às fls. 471/489 respondido às fls. 490/491.

Manifestação da defesa (fls. 502).

Mandado de prisão cumprido às fls. 512/517.

Revogada a suspensão da ação penal e do decurso do prazo prescricional, mantida a prisão preventiva do réu e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 525/527).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 591/595).

Manifestação do Ministério Público (fls. 608).

Decisão de fls. 609 homologou a desistência de oitiva da testemunha Tiago

Apolinário Gomes Filho.

Nesta audiência, realizada de forma virtual, foram inquiridas 02 (duas) testemunhas de acusação, 01 (uma) testemunha de defesa e interrogado o réu.

Encerrada a instrução, em alegações finais, as partes fizeram suas postulações.

É o relatório.

Inicialmente, diferente do que postulado pelo ilustre Promotor de Justiça, inexiste nos autos qualquer cerceamento à acusação no indeferimento da juntada de folhas de antecedentes criminais do acusado no Estado de Mato Grosso, tendo em vista a certidão de fl. 583 recentemente acostada (em 08.06.2022) certificando que a pessoa de EDMAR SÉRGIO TAMURA MACERA não possui antecedentes criminais.

Não bastasse, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 129, VI e VIII, atribui ao órgão Ministerial o poder requisitório, estabelecendo que ele pode exercer, de forma direta, as suas atribuições, objetivando a celeridade dos procedimentos. Do mesmo modo, o artigo 47 do CPP, estabelece que o Ministério Público, se entender necessário, deverá requisitar diretamente, de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los.

Desse modo, inexistente qualquer dificuldade imposta ao Ministério Público, desde, no mínimo, o oferecimento da peça acusatória, para que o órgão obtivesse o documento desejado, não há como procrastinar o curso desta ação penal para realização de tal diligência pela secretaria deste Juízo se a referida diligência muito bem poderia ter sido efetivada pelo órgão acusatório.

A propósito, a secretaria deste Juízo por diversas vezes fez a juntada de tais documentos (fls. 204/206, 289/292, 566/570, 200/203, 293/295, 571/573, 330 e 583). Presentes as condições da ação e não havendo preliminares e prejudiciais a serem apreciadas, passo à análise do mérito.

A materialidade do crime corresponde à prova de sua existência, em outras palavras, são os elementos que demonstram a ocorrência/existência do delito. Na situação sob julgamento, a materialidade restou devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência de autoria conhecida (fls. 12/14, 17/18, 19/22 e 228/229), autos de exibição e apreensão (fls. 158/159 e 230), laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 161/164), relatório de investigação nº 16/21 da Delegacia de Polícia de Icém/SP (fls. 176/177), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 250), laudo pericial de exame de extração de dados de aparelho celular (fls. 314/322), relatório de investigação de verificação de aparelho celular (fls. 349/356), laudo pericial de localização e apreensão de veículo (fls. 426/437), cópia do Termo de Audiência de Instrução, Debates e Julgamento do Processo nº 1500412-16.2021.8.26.0390 (fls. 438/445) e pelas demais provas colhidas no inquérito e em juízo, sob o crivo do contraditório.

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

Referidas provas demonstram, além de qualquer dúvida razoável, a materialidade do

crime.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que o acusado Edmar foi o autor do crime, conforme será devidamente demonstrado a seguir.

Em seu depoimento, Adenir Marcolino da Silva, Policial Militar, disse que estava de serviço quando na altura do Auto Posto 2000, em Paulo de Faria, avistou dois veículos estacionados no acostamento, uma montana vermelha e uma Saveiro. O condutor da GM/MONTANA saiu em direção à Rodovia, no sentido de tráfego Paulo de Faria/SP, sendo que o veículo VW/SAVEIRO o seguiu, mantendo certa distância, o que gerou suspeita da equipe, que resolveu acompanhar os veículos para abordá-los. Relata que, próximo ao presídio de Paulo de Faria, deu sinal de parada aos condutores dos veículos. O veículo GM/MONTANA obedeceu a ordem de parada. O veículo VW/SAVEIRO ignorou e saiu em alta velocidade, sendo acompanhado pela guarnição. O depoente não fez a abordagem do veículo GM/MONTANA, perseguindo o veículo VW/SAVEIRO. O veículo MONTANA, pelo que percebeu, era conduzido por um homem com traços orientais e uma mulher no banco de passageiro. O depoente reconheceu o motorista da SAVEIRO posteriormente em fotos mostradas a ele na delegacia. Foi feito um cerco que ajudou a abordar o veículo VW/SAVEIRO, sendo que em vistoria no veículo por ela conduzido, foram encontrados vários pacotes de substância com característica de entorpecente denominado 'maconha', de fácil visualização, tendo em vista a expressiva quantidade. Posteriormente, o depoente soube que o veículo GM/MONTANA empreendeu fuga e foram acionadas várias viaturas para efetivar a abordagem.

Em seu depoimento, Luís Carlos Teixeira, Policial Civil, disse que na data dos fatos recebeu informações da Polícia Militar de que um veículo havia se evadido da cidade de Icém/SP e tomado o rumo de Paulo de Faria/SP. Saiu em diligência pela cidade e ao passarem por uma vicinal localizaram o veículo abandonado em uma mata. Disse também que ao chegar no local o veículo era uma picape e no seu interior havia alguns objetos, dentre eles um rádio comunicador. Não teve contato com as pessoas que estavam no interior do veículo, mas teve conhecimento que outro veículo foi apreendido com grande quantidade de drogas.

Nélson Cabrera, testemunha de defesa, disse que na última semana de setembro do ano de 2021 o acusado o ajudou numa instalação de rede elétrica na residência localizada na cidade de Presidente Epitácio. Outras pessoas viram o acusado junto com o depoente fazendo a obra. Trata o acusado como "Sérgio". Não sabe com quem o acusado "anda".

Em seu interrogatório, Edmar Sérgio Tramura Macera negou os fatos. Não sabe o porquê é atribuído a ele tal delito. Narra que, na última semana de setembro do ano de 2021, foi fazer uma instalação de energia elétrica num sítio pertencente ao Sr. Nelson, na companhia deste último, o que demorou por volta de três dias, terminando o serviço na quinta feira perto do almoço. No local da obra, moram várias pessoas e elas viram a movimentação dos obreiros. Um outro amigo do acusado, de nome Carlos, ajudou na obra. Desconhece a pessoa de Lucimar, mas conhece Dayani, a qual conheceu por intermédio de Matheus (sobrinho dela). Disse que estava morando com o seu pai em setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021.

Cabe salientar que os policiais, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram uníssonos, coerentes e convincentes. Deste modo, é necessário valorizar tais depoimentos pelo fato de que são agentes públicos que agem no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, calcados na boa-fé presumida, e, assim, são merecedores de toda a confiança, equiparados por qualquer indivíduo do corpo social há de merecer, até que o conjunto probatório confirme em contrário, inexistentes, outrossim, no caso em testilha.

No caso em apreço, também nada há nos autos a indicar desvio funcional que comprometesse a idoneidade da testemunha policial. Neste sentido, não há motivo para excluir-se o depoimento prestado por agente público. Aliás, como servidor público que é, tem na prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES MEIRELLES (Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995).

Nesse diapasão, há posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações”- STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.

O Superior Tribunal de Justiça segue a mesma linha:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DESPROPORÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCLUSÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA. VALORAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. 2. Concluindo a instância ordinária, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, que a acusada praticou tráfico de drogas, porquanto foi vista entregando a sacola com maconha e cocaína ao corréu preso em flagrante, o alcance de entendimento diverso implica no revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 3. Na linha do entendimento esposado por reiterados precedentes deste Tribunal, é permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena-base a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Precedentes. 4. Não caracteriza bis in idem a utilização das circunstâncias da quantidade ou natureza da droga na primeira e terceira fases da dosimetria da pena, nos casos em que a instância ordinária tenha fundamentado a negativa da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em outras circunstâncias concretas, sendo imprópria a via do habeas corpus à revisão do entendimento. 5. Estabelecidas as penas acima de 5 anos de reclusão e havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabível a aplicação do regime inicial fechado, imediatamente mais grave que o correspondente ao quantum da sanção aplicada, nos exatos termos do art. 33, § 2º, a, e § 3º, do CP. 6. Ordem denegada. (HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018) - grifou-se.

Diferente não é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação - Furto qualificado tentado - Condenação - Recurso da defesa - Pedido de absolvição por falta de provas e pela incidência do princípio da insignificância - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova oral harmônica e coesa - Palavra da vítima goza de especial relevância nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade - Depoimento policial constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade - Qualificadora do rompimento de obstáculo comprovada pelas declarações da vítima e, especialmente, pelo laudo pericial - Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância - Ausência de previsão legal - Afronta ao

direito fundamental de propriedade - Cabimento do "furto privilegiado", desde que preenchidos os requisitos legais - Pleito de redução da fração de aumento empregada em virtude da agravante da reincidência (de 1/3 para 1/6) - Descabimento - Reincidência específica autoriza incremento maior que 1/6 - Requerimento de aplicação da fração máxima de diminuição cabível pela tentativa (2/3) - Inviabilidade - "Iter criminis" percorrido pelo agente - Proximidade da consumação - Pedidos de modificação do regime inicial semiaberto para o aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Reincidência específica - Recurso não provido - Erro material da sentença - Promovida a correção da capitulação jurídica do fato - (TJSP; Apelação Criminal 0006797-66.2015.8.26.0066; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 12/02/2021) (grifos acrescidos).

A versão do acusado, de negativa da Autoria do crime que lhe é imputado, não prospera.

Em fase de inquérito, às fls. 06/07, a corré Dayani confirmou estar em companhia do réu no veículo MONTANA e que este sabia da droga:

"a interrogada e SÉRGIO, que estavam no veículo GM/MONTANA conduzido por SÉRGIO, acompanhou durante toda viagem uma mulher na condução de um veículo VW/SAVEIRO. Segundo SÉRGIO, tal mulher estaria transportando eletrônicos. Por volta das 10H00MIN foram abordados por policiais militares, que deram ordem de parada. Como a condutora do veículo VW/SAVEIRO não obedeceu a ordem de parada, os policiais deixaram SÉRGIO e a interrogada e foram atrás da condutora do VW/SAVEIRO. SÉRGIO efetuou manobra e contornou a rodovia, com sentido Presidente Epitácio. Quando percebeu que estava sendo seguido por uma viatura, adentrou numa cidadela, conseguindo se desvencilhar dos policiais, indo para o meio de um matagal. Durante o trajeto, a interrogada indagou SÉRGIO se tinha droga na VW/Saveiro, tendo SÉRGIO confirmado positivamente por gesto (abaixando a cabeça). Quando estavam próximo de uma mata, a interrogada não queria entrar no meio do matagal, mas foi puxada por SÉRGIO, sofrendo ferimentos na região dos braços."

Acrescento que a defesa do acusado não fez prova alguma de que o Réu teria sido vítima de uma "armação" por parte de Dayani, ônus que lhe competia, por força do disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal.

O relatório de investigação anexado aos autos (fls. 176-177) bem detalhou como se chegou ao conhecimento de que o acusado teve participação no crime. O investigador de polícia, Rogério Nunes dos Santos, no dia 05.10.2021, entrou em contato com o setor de investigação da Delegacia do Município de Presidente Epitácio e foi informado pelo agente policial Audrey Cassio da Silva que o "Sergio Japa", cuja qualificação é Edmar Sérgio Tamura Macera, é pessoa conhecida naquela região pelo forte envolvimento com o tráfico de drogas. Em seguida, o policial militar responsável por dar a ordem de parada ao veículo MONTANA (fls. 248-250) reconheceu o acusado como o condutor do veículo em questão.

Assim, a alegação do réu no sentido de que não cometeu o crime em questão restou infirmada pela versão apresentada nos autos, que indica o contrário.

O Réu e a testemunha defensiva tentaram isentar o acusado da responsabilidade criminal ao afirmar que o acusado, na época dos fatos, estava noutro local, instalando uma rede elétrica numa residência localizada na cidade de Presidente Epitácio. Contudo, em que pese indicarem a existência de outras pessoas no local a comprovar a presença do acusado naquela região, nenhuma delas foi arrolada pela defesa, apesar de número possível para isso (fl. 468).

Não bastasse isso, tal versão foi infirmada até mesmo pelo próprio relato do Réu.

No seu interrogatório, afirmou que, durante os meses de setembro a dezembro de 2021, residia com o seu pai, para auxiliá-lo em questão de saúde. Mas o Sr. Leondo Crisóstomo Macera (pai do acusado) respondeu ao Sr. Oficial de Justiça, cujos atos gozam de fé pública, no dia 10 de dezembro de 2021 (fl. 362) que (...) ele - o acusado - não reside há muito tempo no local, que desconhece seu atual paradeiro, afirmando que a última vez que teve contato com o filho por ligação telefônica ele teria afirmado que reside na cidade de Ponta Porã, porém também não forneceu seu endereço nem um número de telefone para contato (...).

Bastava, portanto, para espantar qualquer tipo de dúvida e confirmar a versão defensiva, ter o acusado indicado seu pai como testemunha nestes autos porque, mesmo que ouvido na qualidade de informante, muito bem poderia confirmar que o filho com ele residia em Presidente Epitácio - SP e, na da dos fatos, efetivamente auxiliava o Sr. Nélon na instalação da rede elétrica na mesma cidade.

Também a comprovar que o acusado não estava, na época dos fatos, em Presidente Epitácio - SP colaborando na obra elétrica do terreno do Sr. Nélon, tem-se a declaração prestada pelo seu irmão ao agente policial, no dia 21 de outubro de 2021. O Sr. Bras Hiroki Tamura, que se identificou como irmão do acusado ao agente policial Guilherme Gonçalves Viana, disse ao servidor público, ao ser questionado sobre o paradeiro do acusado, que (...) o mesmo (Edmar) atualmente reside na cidade de Ponta Porã, não sabendo informar precisamente referido domicílio" (fl. 224).

Com efeito, as provas colhidas durante a instrução processual são bastantes a fundamentar um juízo condenatório. Dos depoimentos acima transcritos, infere-se, além de qualquer dúvida razoável, que as drogas apreendidas eram de posse do réu.

Da análise do tipo previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, deve-se observar que a lei não define o que seja traficância. A tal noção, porém, se chega, ao afastar a hipótese de que a posse da droga se destina para o consumo pessoal. Em outras palavras, pela legislação vigente, haverá tráfico quando não houver consumo pessoal.

A Lei de Drogas estabelece alguns critérios que devem guiar a cognição do juiz ou juíza no sentido da determinação do significado do fato penalmente relevante:

Art. 28. (...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Com efeito, considerando a natureza da droga apreendida (maconha), a quantidade (180 tijolos pesando 111,4 Kg), a forma de acondicionamento da substância entorpecente (embalada), a forma como se deu a apreensão da substância (após longa perseguição policial) e as circunstâncias pessoais do Réu (conhecido dos meios policiais por exercer a traficância), infere-se situação que não retrata porte para consumo pessoal.

Deve-se ressaltar que, diante da multiplicidade de condutas previstas no art. 33, caput, da Lei de Drogas, não é necessária a comprovação cabal da mercancia, bastando que haja prova da adequação da conduta a qualquer um dos verbos previstos no tipo penal:

Apelação criminal - Tráfico de drogas - Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - Recurso defensivo buscando a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal ou, subsidiariamente, a redução da pena, afastando-se o aumento de pena em razão de condenação sem trânsito em julgado para o réu, e mediante a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33,

da Lei de Drogas. Materialidade e autoria comprovadas - Prisão em flagrante - Apreensão de 8,98g de cocaína, na forma de crack - Réu que negou a prática delitiva - negativa que não prospera - Policiais Militares que esclareceram as circunstâncias da prisão em flagrante do réu, que é a certeza visual do crime, bem como da apreensão das drogas. Relataram que, após informação de que o réu retornaria da cidade de Dracena, onde foi comprar drogas para posterior comercialização no Município de Ouro Verde, deslocaram-se até a Rodoviária e aguardaram o retorno dele. Visualizaram o réu descer do ônibus e ele, ao perceber a presença policial, tentou se desfazer da droga. Realizada a abordagem e indagado, o acusado declarou que a droga destinava-se ao seu consumo próprio. A droga foi localizada, e constataram se tratar de uma porção de crack, que não estava fracionada, e não poderia ser consumida naquele estado, sem antes fracioná-la. Réu que é conhecido pela alcunha 'Boliviano', e pela prática de tráfico de drogas, com prisão anterior pela prática do mesmo delito. Droga apreendida com o réu que renderia entre trinta a quarenta porções de crack - Tráfico de drogas consumado - Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas - Prova que demonstrou efetivamente a ocorrência de tráfico de entorpecentes - condenação de rigor, nos termos da denúncia. Dosimetria - Pena-base fundamentadamente exasperada - Sem alteração na segunda e terceira fases. Não cabimento do redutor de pena, por falta de amparo legal Não cabimento de penas restritivas de direitos, por falta de amparo legal Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado no caso concreto. Recurso da Defesa improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0001325-64.2018.8.26.0168; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019) (grifos acrescidos).

Com relação ao inciso V do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006, crime de tráfico entre Estados da Federação, ressalte-se que o Réu efetivou a transposição da divisa interestadual. A droga foi remetida da cidade de Campo Grande/MS e tinha por destino a cidade de São José do Rio Preto/SP. Ainda que não tenham sido apreendidos comprovantes de pedágios, a prova oral produzida em juízo deixa evidente o deslocamento interestadual. A jurisprudência chega a dispensar o efetivo transpasse de fronteira, quando evidente a intenção de transporte para outro Estado da federação:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE INTERESTADUAL. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A solução da controvérsia não exigiu o revolvimento do material cognitivo produzido nos autos - providência realmente vedada, em sede de Recurso Especial, pela Súmula n. 7 do STJ -, mas apenas a reavaliação dos fatos exaustivamente descritos pelas instâncias ordinárias. - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei 11.343/2006, é irrelevante a efetiva transposição da divisa interestadual, vez que o tráfico interestadual se configura com a comprovação de que a substância estava sendo transportada de um estado a outro, sendo suficiente que, pelos meios de prova, se evidencie que a droga teria como destino estado da Federação diverso daquele em que foi apreendida. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no Resp: 1434027 PR 2014/0028868-6, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 20/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2014).

À vista de todos esses elementos, conclui-se que o réu, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 33, 'caput', c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao menos a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

No entanto, as provas foram suficientemente apresentadas e comprovam o teor da ilicitude através dos autos produzidos durante a fase policial e processual, quanto a quantidade do entorpecente e a forma de seu acondicionamento.

Além disso, inexistente nos autos qualquer elemento que aponte que ele agiu de forma justificada. Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto à culpabilidade, esta analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto aos autores, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, porquanto o réu é imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu Edmar Sergio Tamura Macera pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06.

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Passo a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06.

A culpabilidade consiste no grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, a culpabilidade é anormal a espécie e isso porque a apreensão do veículo utilizado pelo acusado para a traficância só foi possível após perseguição policial. Em relação aos antecedentes, trata-se de acusado sem antecedentes criminais na forma da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não poderá ser considerada negativa. Não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a conduta social não pode ser valorada negativamente. Não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do agente, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente. Os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário. As circunstâncias do crime excedem o que se espera em condições normais, tendo em vista que foi necessária a utilização de força policial intensa para a captura dos veículos usados pelo Réu, inclusive com utilização de helicóptero. As consequências do crime são aquelas que se devem ordinariamente esperar do delito em questão. Trata-se de crime sem vítima determinada, motivo pelo qual tal circunstância será valorada como neutra. Visando não incidir in bis in idem, a natureza e a quantidade da droga serão valoradas apenas na terceira fase da dosimetria.

Assim, nesta primeira etapa, fixo a pena base em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas e, por isso, a pena é fixada no mesmo patamar.



Quanto à terceira-fase, é preciso enfrentar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, que assim dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre a figura do tráfico privilegiado, cumpre firmar, desde já, algumas premissas, colhidas da pacífica jurisprudência dos tribunais superiores:

(i) a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes (HC 510077/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25/06/2019, DJe 05/08/2019; AgRg no REsp 1449194/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26/09/2017, DJe 04/10/2017); e

(ii) a quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no art. 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando evidenciada a dedicação à atividade criminosa (AgRg no HC 668.599/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/06/2021, DJe 18/06/2021; AgRg no REsp 1924209/MG, Rel. Min. Feliz Fischer, Quinta Turma, j.m 13/04/2021, DJe 26/04/2021).

No presente caso, fica afastado tal benefício.

Há que se considerar que foram encontrados 180 'tijolos de maconha', pesando cerca de 111,4 kg. Não se trata, tendo em vista a quantidade das drogas apreendidas e a forma usada para acondicionar, de tráfico pontual ou isolado exercido pelo Réu, não sendo o caso, portanto, de aplicação do chamado tráfico privilegiado.

A quantidade da droga apreendida, portanto, serve como parâmetro, aliada a outras circunstâncias, que o agente faz da traficância uma prática habitual, afastando a aplicação do redutor que tem como campo de incidência a resposta punitiva mais branda ao pequeno traficante que se envolve de modo eventual com a criminalidade. Importante aqui registrar que o acusado não comprovou qualquer ocupação lícita antes dos fatos aqui discutidos, o que só ratifica a necessidade de afastamento do tráfico privilegiado.

Nesse mesmo sentido, Renato Brasileiro:

(...) se o indivíduo for flagrado com grande quantidade e variedade de drogas, tem-se aí forte indicativo de que se trata de agente dedicado a atividades criminosas, até mesmo porque não é normal que um traficante pequeno e eventual dê início às atividades de traficância com tamanha quantidade e diversidade de drogas (Legislação criminal especial comentada: volume único / Renato Brasileiro de Lima - 4 ed. - Salvador: JusPODIVM, 2016).

Com efeito, pese a quantidade de entorpecente apreendido, por si só, não ser obstáculo à concessão da benesse, no específico caso dos autos compõe cenário em que evidente a participação do réu em organização criminosa, somado ao relatório (fls.176-177) elaborado pelo expert que evidencia a participação deste Réu noutras atividades ilícitas. Igualmente já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Conformismo defensivo quanto ao mérito da condenação – Afastamento dos maus antecedentes reconhecidos indevidamente – Possibilidade de exasperação da básica em menor fração em razão da natureza da substância apreendida, pese a quantidade – Acerto da redução pela confissão em apenas 1/6, fração paradigma – Descabimento de aplicação da redutora do art. 33, § 4º, L. 11.343/06 – Circunstâncias fáticas que indicam envolvimento com organização criminosa e dedicação a atividades criminosas – Manutenção do regime prisional fechado em razão do montante da pena e dolo exacerbado – Insuficiência do tempo de prisão processual à detração do art. 387, § 2º, CPP – Pena de multa imposta conforme os parâmetros legais – Descabimento de afastamento das custas processuais – Recurso parcialmente provido (voto nº 45116). (TJSP; Apelação Criminal 1502029-96.2020.8.26.0664; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Votuporanga - 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 25/08/2021; Data de Registro: 25/08/2021) – grifou-se.

Assim já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível avaliar a quantidade da droga para aumentar a pena-base, bem como para afastar o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na terceira fase da dosimetria, desde que aliada à outras circunstâncias do delito que evidenciem a dedicação à atividade criminosa ou a participação em organização criminosa, sem ofensa ao princípio do non bis in idem” (AgRg no AgRg no AREsp 1508953/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019).

Assim já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível avaliar a quantidade da droga para aumentar a pena-base, bem como para afastar o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na terceira fase da dosimetria, desde que aliada à outras circunstâncias do delito que evidenciem a dedicação à atividade criminosa ou a participação em organização criminosa, sem ofensa ao princípio do non bis in idem” (AgRg no AgRg no AREsp 1508953/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019).

Enfim, ficou demonstrado através do conjunto probatório que as atividades exercidas pelo acusado não eram as de um traficante ocasional e solitário. Pelo contrário, a ele foi confiado valiosa carga de entorpecentes, o que demonstra não ser novato na atividade criminosa, mas sim ter habitualidade e dedicação à narcotraficância, se utilizando dela como meio de vida, não reunindo mérito para o benefício.

Por outro lado, deve incidir a causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, porque a droga estava sendo transportada do Estado de Mato Grosso do Sul para São Paulo. Tendo em vista que a droga foi apreendida na rodovia SP 322, local próximo ao se destino (São José do Rio Preto), majoro a pena em 1/3 (um terço).

Assim, a pena em definitivo ficará em 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. Fixo cada dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

Aplicada pena privativa de liberdade em patamar superior a oito anos, em obediência ao que estabelece o art. 33, § 2º, “a” do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Uma vez fixada pena privativa de liberdade em quantidade superior a quatro anos, mostra-se inviável a sua substituição por penas restritivas de direitos, pois não atendidos os requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal. Incabível o sursis, em razão da quantidade de pena, nos termos do artigo 77 e seguintes do Código

Penal.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o réu EDMAR SÉRGIO TAMURA MACERA, nascido aos 23/03/1979, filho de Leondo Chrysostomo Macera e de Marina Yoco Tamura Macera, pela prática do crime previsto no artigo 33, 'caput', c.c. artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no patamar fixado.

CONDENO o sentenciado ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804).

O acusado encontra-se preso por este processo e, conforme a determinação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, não concedo a ele o direito de recorrer em liberdade em relação aos fatos aqui apurados, uma vez que a permanência dele no cárcere é necessário para a manutenção da ordem pública.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o fumus comissi delicti decorre da própria procedência da pretensão punitiva veiculada na denúncia, havendo prova da materialidade e indícios de autoria do crime atribuído ao réu.

O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto do crime praticado pelo réu, do risco concreto de ele voltar a delinquir, bem como da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não existem garantias de que em liberdade não se afastará do distrito da culpa.

Recomende-se ao cárcere em que se encontra.

Nesse sentido, o acusado durante longo tempo não foi localizado pela Autoridade Policial, permanecendo em lugar ignorado até tempos atrás (fls. 224). Além disso, ele já possui antecedentes (fls. 200/203 e 204/206), ressaltando, ainda, a grande quantidade de drogas apreendidas (180 tijolos de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", pesando 111,4 KG). Esses fatores, somados, levam a crer que, em liberdade, o acusado voltará a praticar delitos e também não respeitará a aplicação da lei penal.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação do dano porque a questão não foi submetida ao contraditório.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores e bens apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis, se o caso.

Considerando a demonstração de que o veículo apreendido (fl. 242) foi utilizado para o tráfico de drogas, sobretudo para o transporte das drogas apreendidas nestes autos, com fundamento no art. 91, II, "b", do Código Penal c/c art. 63, I, da Lei 11.343/06, como efeito secundário da condenação, DECRETO o perdimento em favor da União do veículo em questão.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que:

"É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal." (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017).

Ademais:

"(...) A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. Assim, havendo as instâncias de origem concluído pela utilização do veículo para os fins de tráfico de entorpecentes e, por conseguinte, determinado sua expropriação, não há como esta Corte Superior concluir em sentido contrário, porquanto demandaria a imersão vertical no acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na via processual eleita(...).AgRg nos EDcl no REsp

Deixo de aplicar detração porque inexistem outros elementos, como comportamento carcerário, a possibilitar a aplicação da benesse.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva, encaminhando-se ao juízo das execuções criminais.

DETERMINO a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (art. 72, da Lei nº. 11.343/2006), caso a providência já não tenha sido adotada.

Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

P.R.I.

Nova Granada, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA